

1500317-56.2019.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2181392/2019 - DEL.POL.ARARAS, 5919195 - DEL.POL.ARARAS, 3621/19/805 -

DEL.POL.ARARAS, 2181392 - DEL.POL.ARARAS, 3621/19/805 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500317-56.2019.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500317-56.2019.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2181392/2019 - DEL.POL.ARARAS, 5919195 - DEL.POL.ARARAS, 3621/19/805 -

DEL.POL.ARARAS, 2181392 - DEL.POL.ARARAS, 3621/19/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 21h10, na Rua José Dezoti, Parque das Árvores, nesta cidade e Comarca de Araras, o réu trazia consigo drogas destinadas a consumo de terceiros, consistindo em 5,6 g (peso líquido) de cocaína, distribuídas em 18 (dezoito) eppendorfs, conforme auto de constatação preliminar encartado a fls. 15 e laudo de fls. 75/77, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 178) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 200). A denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2020 (fls. 202/203) e o acusado

foi devidamente citado (fls. 278).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (fls. 306/307), bem como interrogado o réu (fls. 308).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 333/339 - réu e 304/305 - MP). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou, em suma, seja o réu absolvido por falta de provas, ou, subsidiariamente, seja o crime desclassificado para o artigo 28 da lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Refuto preliminar de defesa.

Com efeito, de partida, como se sabe, o julgador não está obrigado a determinar que se faça o exame de dependência toxicológica, mas somente quando houver a possibilidade de inimizabilidade do acusado, ainda que de forma reduzida.

Assim, é somente imprescindível a instauração quando houver dúvida acerca da insanidade ou da dependência toxicológica.

Confira-se, a esse respeito, julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:

“O Código de Processo Penal obriga ao exame quando houver dúvida sobre a insanidade e não quando a defesa o requeira. Assim, o Magistrado somente deferirá o requerimento de instauração de incidente de insanidade mental quando presentes indícios de perturbação ou algum motivo, pelo menos, para duvidar da normalidade psíquica, que é regra geral” (TACRIM-SP, JUTACRIM 84/206).

Lembre-se que mero uso de drogas, ainda que prolongado, não implica necessariamente em dependência química.

No mais, conforme entendimento majoritário no STJ (HC 258463/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma) a mera suspeita ou afirmação de que o acusado seja usuário de substâncias ilícitas não justifica a realização de exame em análise.

Vejamos:

“A simples alegação de ser o réu viciado em substâncias entorpecentes não obriga o magistrado a realizar o exame de dependência toxicológica, porquanto cabe ao juiz, no caso concreto, avaliar a conveniência e a oportunidade de sua realização” (RHC 14.789/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª. Turma, julgado em 07.10.2003, DJ 10.11.2003 p. 198)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes Preliminar - Nulidade decorrente do indeferimento de realização de exame toxicológico Inocorrência. Ausência de indícios de que a corré Eliane era inimputável pela dependência química. Prescindibilidade da perícia”. (TJSP, 4ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0001016-16.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Camilo Léllis, São Paulo, 31 de janeiro de 2017).

No mérito, improcede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 13/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pelas fotografias (fls. 17),

pelo auto de constatação de substância entorpecente (fls. 18) e laudo químico-toxicológico de fls. 78/80, bem como pelas provas orais produzidas.

Interrogado, o réu Alexsandro da Silva Santos negou a prática de tráfico. Relatou ter sido abordado em praça pública pelos guardas municipais. Negou a propriedade das drogas apreendidas, alegando que foram jogadas por outro rapaz que fugiu da abordagem (fls. 308).

O guarda municipal Celso de Souza Teixeira relatou ter sido acionado para atender a uma ocorrência relacionada a tráfico de drogas. Ao chegar no local encontrou o réu sentado num banco de praça e que, em revista pessoal, com ele encontrou uma pochete contendo entorpecentes e dinheiro (fls. 306).

O guarda municipal Genecir Aparecido de Oliveira recordou-se vagamente dos fatos, limitando-se a dizer que foi acionado sobre a prática de tráfico com a menção das características do criminoso. Chegando ao local indicado, abordou o réu em posse de drogas e dinheiro, razão pela qual foi preso.

As respostas dadas por Genecir após a leitura de seu depoimento na fase extrajudicial pelo órgão ministerial não podem ser consideradas, eis que não são juridicamente válidas indagações que puderem induzir a resposta (art. 212, do CPP).

São as provas.

De rigor o reconhecimento da nulidade na atuação da guarda municipal. Vejamos:

Importante salientar que prisões em flagrante efetuadas por Guardas Civis Municipais não são, por si só, não inválidas, sendo possível aos servidores municipais que a efetivem em caso de visibilidade da conduta ilícita.

Nesse sentido, segundo o artigo 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (grifamos).

Todavia, não é esse o caso destes autos.

Não havia flagrância delitiva visual apta a justificar a abordagem realizadas pelos guardas no caso em apreço.

De fato, os agentes municipais foram acionados sobre a prática de tráfico por pessoa com determinadas características em determinado local. Lá chegando, sem nada de anormal ou ilegal avistarem, abordaram o réu, realizaram revista pessoal e fizeram sua prisão.

Desta feita, resta evidente que os guardas civis municipais exerceram função típica de polícia ostensiva, função de incumbência da Polícia Militar, bem como atividade investigativa, tarefa da Polícia Civil.

A prisão decorreu de verdadeiro trabalho de policiamento ostensivo e investigativo, em atuação típica da polícia militar e/ou civil.

Situação diversa teria sido se o acusado tivesse sido visto pelos guardas em franca atitude de traficância.

Não foi o que aconteceu no caso em análise em que pueril suspeita advinda de delação anônima (que não tem força de prova em juízo) justificou a ação ilegal dos servidores que agiram fora de suas atribuições, ferindo o art. 144, da CF/1988.

Ademais, a Lei Federal de nº 13.022/2014, que estabeleceu as competências das

guardas civis municipais, não pode alterar determinação constitucional para autorizar as guardas civis municipais a exercerem atividades típicas da polícia militar e da polícia civil.

Tanto é assim que o Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 154.743-0/0-00 (autos nº 9039481-58.2007.8.26.0000), realizado em 10 de dezembro de 2008, em voto condutor da lavra do Eminente e Culto Desembargador, Doutor Maurício Ferreira Leite, teve oportunidade de decidir e nos ensinar que:

"(...) A faculdade outorgada aos municípios de criação de suas guardas não lhes concede o direito de extrapolar os limites ali impostos, ou seja, visam unicamente a proteção de seus bens, serviços e instalações, devendo ser repelida qualquer tentativa de alargamento desse horizonte, quando mais se constatada invasão a outras esferas."

Outros Tribunais têm deliberado no mesmo sentido:

"(...). Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.(...)" (grifamos STJ, RHC nº 142.588/PR, 6ª Turma, Rel. o Min. OLINDO MENEZES, j. em 25.05.2021).

" (...) Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova. 3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, conseqüentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP" (STJ, HC nº 561.329/SP, 6ª Turma, Rel. o Min. Nefi Cordeiro, j. em 16.06.2020, DJe 29.06.2020)

"Investigação e prisão em flagrante em função típica de policiamento ostensivo, iniciada por ação típica de Polícia Judiciária, por Guardas Civis Municipais Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar e/ou à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Relaxado o flagrante, em liminar, confirmada Nulidade processual ab ovo a ser reconhecida Trancamento da ação penal, de ofício, como consequência.". (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2277974-66.2021.8.26.0000)

"Apelação Criminal. Condenação pelo artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Preliminar acolhida. Prova ilícita. Guarda Municipal. Denúncia anônima. Busca domiciliar. Investigação criminal. Patrulhamento ostensivo e realização de busca e apreensão não é função da Guarda Civil Municipal. Inexistência de situação de flagrância. Ilegalidade da prova. Inteligência do artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Guarda civil municipal está destinada à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Absolvição por insuficiência probatória. Apelo parcialmente provido". (TJSP, APELAÇÃO CRIMINAL nº 1502753-49.2019.8.26.0272)

"Crimes de estelionato e corrupção de menores - Reformatio in melius com base no artigo 617 do Código de Processo Penal - Precedentes desta 12ª Câmara de Direito Criminal e do Superior Tribunal de Justiça - Abordagem realizada em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais e em verdadeira atividade

investigativa, funções típicas reservadas constitucionalmente à Polícia Militar e à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Prova ilícita Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO". (TJSP, Apelação Criminal nº 0002166-05.2017.8.26.0068)

Nulas as provas colhidas desde a prisão, tem-se como consequência a absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS, já qualificado nos autos, nos moldes da fundamentação, por falta de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos e perdimento da quantia apreendida.

Arbitro os honorários aos defensores dativos de acordo com sua atuação processual, inclusive para a defensora de fls.340, expedindo-se a competente certidão.

P.R.I.

Araras, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA